

1026823-97.2021.8.26.0053

Classe: Mandado de Segurança Cível

Assunto: Aposentadoria / Pensão Especial

Magistrado: JOSE EDUARDO CORDEIRO ROCHA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 14ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... apenas reduziu a sanção (fls. 963/985). Quanto ao tráfico e ocultação de entorpecentes em residência de terceira pessoa com o intuito de forjar flagrante, relativo à ação penal nº 1000726-05.2019.8.26.0288, a condenação pelos crimes de tráfico e denúncia caluniosa foi ratificada pelo TJSP (fls. 986/1090).

Portanto, na seara criminal, inexistente absolvição em favor do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

14ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1026823-97.2021.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1026823-97.2021.8.26.0053

Classe - Assunto

Mandado de Segurança Cível - Aposentadoria / Pensão Especial

Impetrante:

Aginaldo Costa dos Santos

Impetrado:

Secretaria de Segurança Pública - Representada Pelo Secretário de Segurança

Pública-com Pol. Ambiental

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO CORDEIRO ROCHA

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por AGNALDO COSTA DOS SANTOS contra suposto ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Relata, em síntese, que atuava como investigador de polícia, encontrando-se aposentado desde agosto de 2019. Informa que teve contra si instaurados quatro procedimentos administrativos disciplinares, condenado a pena de cassação da aposentadoria em três deles. Contudo, teve seu benefício extinto antes mesmo do trânsito em julgado das respectivas ações penais. Alega violação do devido processo e que a prematura cessação do pagamento não encontra amparo no ordenamento jurídico. Apesar de estar detido, tem sob sua responsabilidade o sustento de sua esposa e dois filhos menores. Requer a cassação das decisões administrativas dos processos administrativos nº CA 002/19, CA 007/19 e CA 008/19, bem como o restabelecimento de seus proventos de aposentadoria, devendo o impetrado se abster

de aplicar penalidades até o trânsito em julgado das ações penais correlatas. O pedido veio acompanhado de documentos (fls. 20/1110).

Indeferida a liminar e concedida a gratuidade processual (fls. 1112/1113).

Opostos embargos de declaração (fls. 1117/1122), que foram rejeitados (fls. 1130).

O impetrado apresentou informações, instruídas com documentos (fls. 1147/1176). Em preliminar, suscitou ausência de direito líquido e certo. No mérito, pugnou pela denegação da ordem, ao argumento de que os processos administrativos transcorreram regularmente e, após instrução, foram aplicadas, nos três processos em discussão, a pena de cassação da aposentadoria. Pontua que o fato de inexistir desfecho nas ações penais correspondentes não impede a responsabilização disciplinar no PAD, tendo em vista a independência entre as instâncias penal e administrativa.

O Ministério Público opinou pela denegação da segurança (fls. 1179/1185).

É o relatório.

DECIDO.

A preliminar de inexistência de direito líquido e certo confunde-se com o mérito e, como tal, será analisada.

No mérito, os autos estão prontos para o julgamento.

A questão central debatida versa sobre a possibilidade de afastamento da pena de cassação da aposentadoria aplicada em três processos administrativos disciplinares instaurados contra o impetrante, em virtude da ausência de trânsito em julgado nas respectivas ações penais.

O processo administrativo disciplinar, no âmbito da Polícia Civil do Estado de São Paulo, é regulado da Lei Complementar nº 207/79 - Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo - LOP. Os artigos 87 e seguintes da norma versam sobre a matéria, dentre os quais, destacam-se:

Artigo 87 - A apuração das infrações será feita mediante sindicância ou processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Artigo 89 - Será obrigatório o processo administrativo quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar a pena de demissão, demissão a bem do serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. (...)

Artigo 92 - Aplicam-se à sindicância as regras previstas nesta lei complementar para o processo administrativo, com as seguintes modificações:

I - a autoridade sindicante e cada acusado poderão arrolar até 3 (três) testemunhas;

II - a sindicância deverá estar concluída no prazo de 60 (sessenta) dias;

III - com o relatório, a sindicância será enviada à autoridade competente para a decisão. (...)

Artigo 114 - Relatado, o processo será encaminhado ao Delegado Geral de Polícia, que o submeterá ao Conselho da Polícia Civil, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

§ 1º - O Presidente do Conselho da Polícia Civil, no prazo de 20 (vinte) dias, poderá determinar a realização de diligência, sempre que necessário ao esclarecimento dos fatos.

§ 2º - Determinada a diligência, a autoridade encarregada do processo administrativo terá prazo de 15 (quinze) dias para seu cumprimento, abrindo vista à

defesa para manifestar-se em 5 (cinco) dias.

§ 3º - Cumpridas as diligências, o Conselho da Polícia Civil emitirá parecer conclusivo, no prazo de 20 (vinte) dias, encaminhando os autos ao Delegado Geral de Polícia.

§ 4º - O Delegado Geral de Polícia, no prazo de 10 (dez) dias, emitirá manifestação conclusiva e encaminhará o processo administrativo à autoridade competente para decisão.

§ 5º - A autoridade que proferir decisão determinará os atos dela decorrentes e as providências necessárias a sua execução. (NR)

Como é cediço, os atos administrativos sujeitam-se ao controle judicial. Todavia, não pode o Judiciário imiscuir-se no mérito de atos reservados à apreciação subjetiva da Administração Pública. Isso porque o controle judicial não abrange aspectos de conveniência e oportunidade. O mérito administrativo compete ao administrador público, que analisa as hipóteses que lhe são submetidas e decide em conformidade com o disposto em lei.

Os procedimentos administrativos foram instaurados contra o demandante porque teria concorrido com organização criminosa envolvida com a prática de jogo do bicho, lavagem de dinheiro e corrupção, na região abrangida pelo DEINTER 3, além de ter mantido a posse irregular de arma de fogo em sua residência e ter intrujado entorpecentes, em concurso de agentes, no quintal de pessoa para prendê-la em flagrante.

A leitura da documentação acostada aos autos revela que a apuração dos fatos, em âmbito administrativo, desenvolveu-se de forma regular, inexistindo vícios que maculassem os procedimentos administrativos e levassem às suas anulações.

Quanto à penalidade estabelecida, dispõe o art. 69 da LOP que “na aplicação das penas disciplinares serão considerados a natureza, a gravidade, os motivos determinantes e a repercussão da infração, os danos causados, a personalidade e os antecedentes do agente, a intensidade do dolo ou o grau de culpa”.

Não se vislumbra, repise-se, do ponto de vista formal, mácula a ensejar a anulação dos três procedimentos, que atenderam ao disposto na LOP.

Vale destacar que as decisões nos PAD's expressamente referem que as ações penais correlatas se encontram em andamento (fls. 1148, 1153 e 1158), porém igualmente mencionam que restou comprovado, em sede administrativa, as condutas imputadas ao policial aposentado, ensejando a penalidade disciplinar.

Observa-se ainda a regular tramitação dos feitos, assegurada a ampla defesa e o contraditório ao acusado, ora autor, conforme evidencia a documentação juntada pelo impetrante (fls. 28/666).

As faltas graves foram devidamente identificadas e motivadas, bem como, de acordo com critérios da Administração, aplicada sanção proporcional.

Outrossim, verifica-se que, no processo criminal nº 1002464-28.2019.8.26.0288, o impetrante foi condenado, em primeira instância, pelos delitos de corrupção passiva e organização criminosa (fls. 889/953). Já nos autos do processo nº 1500167-88.2019, foi condenado pela posse irregular de arma de fogo de uso permitido, decisão confirmada pelo TJSP, que apenas reduziu a sanção (fls. 963/985). Quanto ao tráfico e ocultação de entorpecentes em residência de terceira pessoa com o intuito de forjar flagrante, relativo à ação penal nº 1000726-05.2019.8.26.0288, a condenação pelos crimes de tráfico e denúncia caluniosa foi ratificada pelo TJSP (fls. 986/1090).

Portanto, na seara criminal, inexistente absolvição em favor do impetrante e, mesmo

que houvesse, apenas decisão judicial que reconhecesse a inexistência dos fatos ou a negativa de autoria poderia beneficiá-lo. A mera absolvição por falta de provas não afasta a avaliação da conduta do réu pelo prisma funcional e de correção de conduta como policial. Como bem assinalou a promotora “é perfeitamente possível que determinados fatos constituam infrações administrativas, mas não ilícitos penais, permitindo a aplicação de penalidade ao servidor pela Administração, sem que haja a correspondente aplicação de penalidade na esfera criminal” (fl. 1183).

Nesse cenário, ante a comprovação de diversas condutas irregulares pelo policial, há que prevalecer a independência entre as instâncias e a preservação das decisões administrativas que aplicaram a pena de cassação de sua aposentadoria.

Acerca do tema, explica a doutrina:

“Não há direito adquirido do servidor ao benefício da aposentadoria, se tiver dado ensejo, enquanto em atividade, à pena de demissão. Por isso, inteiramente cabível a cassação, que pode atingir qualquer tipo de aposentadoria. Até mesmo a extinta aposentadoria compulsória, sanção aplicada a magistrados, poderia ser posteriormente cassada, quando decretada, na ação própria, a perda do cargo. Sanção dessa natureza tende a evitar que a aposentadoria sirva como escudo para escamotear infrações gravíssimas cometidas pelo ex-servidor anteriormente, sem que se lhe aplique a necessária e justa sanção, além do fato de se permitir que usufrua uma inatividade remunerada. Desse modo, quando o servidor passa à inatividade a fim de fugir à responsabilidade funcional, e posteriormente se conclui, em regular processo disciplinar, no sentido de que praticou falta gravíssima, a pena de cassação de aposentadoria é legítima e se apresenta com duplo efeito: invalida o ato de aposentadoria e traduz a aplicação de penalidade equivalente à de demissão.”

Em sintonia, já decidiu o STF:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes. 4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 6. Arguição conhecida e julgada improcedente. (STF, ADPF 418, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020).

Por fim, oportuna a leitura dos julgados do TJSP:

APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - Pretensão do autor à anulação do ato administrativo que impôs a cassação de aposentadoria - Ao Poder Judiciário exclusivamente a apreciação da legalidade, do respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, bem com da proporcionalidade e razoabilidade dos atos administrativos disciplinares - Inexistência de bis in idem entre os diferentes PADs, que possuem objetos diversos - Absolvição na esfera penal em razão de o fato não constituir infração penal sem repercussão na seara administrativa - Proporcionalidade e razoabilidade da sanção - Legalidade da pena de cassação de aposentadoria - ADPF 418 - Sentença de improcedência mantida - Apelação desprovida. (TJSP; Apelação Cível 1028824-89.2020.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)

Apelação - Mandado de segurança - Servidor público estadual aposentado - Agente Fiscal de Rendas - Pretensão à anulação de penalidade aplicada em processo administrativo disciplinar de cassação da aposentadoria - Inadmissibilidade - Legislação estadual que ampara a cassação de aposentadoria - Autor que praticou, quando em atividade, infração disciplinar grave para a qual é cominada a pena de demissão - Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1045293-21.2017.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/03/2022; Data de Registro: 25/03/2022)

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO - Policial civil - Processo Administrativo Disciplinar - Cassação da aposentadoria - Pretendido reconhecimento da nulidade do ato de demissão, com a consequente restituição dos proventos de aposentadoria - Impossibilidade - Regularidade do processo administrativo, com observância das formalidades legais, contraditório e ampla defesa - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ - Súmula 18 do STF - Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0019801-73.2019.8.26.0053; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 02/12/2021)

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA e, por via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Indevida condenação em honorários advocatícios (conforme artigo 25 da Lei nº 12.016/2009, Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça).

Eventuais custas e despesas processuais deverão ser suportadas pela impetrante, isento em razão da gratuidade deferida à fl. 1112.

P.I.C.

São Paulo, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA